

其次，判处罚没车辆应符合罪刑相适应原则。本案各个被告人刑期在有期徒刑九个月左右，罚金在5000元，而违法所得在2000元左右，而车辆本身价值数万元，如果车辆被没收，银行必然追究被告人剩余贷款的民事责任，被告人所承担的责任畸重，不符合罪责刑相适应原则。

最后，某些贷款购买的车辆被告人并不具备完全所有权。实践中有些按揭购买的车辆是约定了所有权何时转移的，有些车辆正在还贷，但尚未取得所有权，此外，也有车辆是与夫妻、家人共有的，如果判决没收此车辆，相当于间接侵害了其他权利人的合法权益，尤其是银行的抵押担保权。因此是否没收作为作案工具的车辆应综合考虑、结合案情、实际，既不能导致国家罚没财产损失，也不能损害相关债权人合法权益。

编写人：广西壮族自治区岑溪市人民法院 欧阳豪

以牟利为目的帮助他人伪造材料申请 “APEC（亚太经合组织）商务旅行卡”并 出售的行为构成出售出入境证件罪

——苏某某、朱某出售出入境证件案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市中级人民法院（2023）苏01刑终472号刑事裁定书

2. 案由：出售出入境证件罪

【基本案情】

被告人苏某某原系某对外交流公司工作人员，2017年2月借调至某港商协会工作。2018年8月，某港商协会与A公司签订协议推广APEC商务旅行卡（以下简称APEC卡），某港商协会将外办授权的APEC卡申报端口的账户密码交给A公司操作。2018年10月，苏某某与A公司法定代表人邹某（另案处理）成立B公司，并取得APEC卡申报端口的账户密码。

为招揽购买APEC卡的客户，被告人苏某某联系到被告人朱某等人，朱某通过中介路某结识C公司总经理王某，并商议通过C公司下属的网点及互联网广告等方式寻找购买客源。王某等人以每张卡约5~9万元（以下币种均为人民币）不等的价格对外出售APEC卡。朱某以每张卡3~5万元的价格从王某处收取费用。苏某某以每张卡2万元左右的价格从朱某处收取费用。王某等人将所收取的购卡人不合规办卡信息发送给朱某，再由朱某发送给苏某某处。苏某某自己或安排韩某某等人，为购卡人伪造社保证明、无犯罪记录证明、工作履历、工作单位等，并以某港商协会的端口为上述购卡人申请APEC卡。办卡成功后，苏某某领取APEC卡并逐级快递给购卡人员。

截至案发，被告人苏某某提交申办APEC卡人员共计261人，有206人的申请资料造假，已成功制卡92人，已售卡88张。其中，被告人朱某与苏某某已提交申办APEC卡人员共计107人，已成功制卡50人，出售48张。

经审计，在上述事项中，王某相关账户向106名购卡人共计收款约572.95万元，其中向已领卡的47人共计收款约350.6万元；王某相关账户支付给朱某相关账户257万元；韩某支付给朱某5万元；王某相关账户支付给苏某某相关账户63.7万元；朱某支付给苏某某相关账户59.502万元。2021年10月15日至11月9日，朱某收到苏某某相关账户退款共计12.5万元；2021年11月29日至12月2日，王某相关账户收到朱某退款共计28万元。

2021年12月18日，被告人朱某被公安机关抓获归案；同年12月28日，被告人苏某某被公安机关抓获归案。归案后，两被告人均未能如实供述上述事实。

【案件焦点】

1. APEC 商务旅行卡是否属于《中华人民共和国刑法》规定的出入境证件；
2. 苏某某、朱某的行为是否属于代办行为，二被告人行为如何定性。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市鼓楼区人民法院经审理认为：被告人苏某某、朱某向他人出售出入境证件，情节严重，其行为均已构成出售出入境证件罪，系共同犯罪，依法应予惩处。苏某某提交申办APEC卡共有206人的申请材料造假，已成功申领92张，出售88张；朱某通过苏某某提交申办APEC卡人员共计107人申请材料造假，已成功申领50张，出售48张。两被告人已经申领未售出APEC卡的行为应当认定为未遂，依法可从轻处罚。

江苏省南京市鼓楼区人民法院依据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，作出如下判决：

一、被告人苏某某犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40万元；

被告人朱某犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。

二、责令被告人苏某某、朱某共同退出违法所得325.7万元，予以没收，上缴国库。扣押在公安机关的APEC卡，由扣押机关依法处置。

苏某某不服一审判决，以“APEC商务旅行卡不属于《中华人民共和国刑法》规定的出入境证件；其行为没有侵害我国出入境秩序，不构成犯罪”为由，向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。江苏省南京市中级人民法院经审理后同意一审法院裁判意见。江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于APEC商务旅行卡是否属于《中华人民共和国刑法》规定的出入境证件以及苏某某、朱某的行为是否属于代办行为，二被告人的行为如何定性。

一、APEC商务旅行卡属于《中华人民共和国刑法》规定的出入境证件

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，出入境证件包括护照或者代替护照使用的国际旅行证件，中华人民共和国海员证，中华人民共和国出入境通行证，中华人民共和国旅行证，中国公民往来香港、澳门、台湾地区证件，边境地区出入境通行证，签证、签注，出国(境)证明、名单，以及其他出境时需要查验的资料。

具体到本案中，APEC商务旅行卡虽不属于上述解释明确列举的出入境证件，但判断其是否属于出入境证件应从其实际功能进行分析。首先，《中华人民共和国出境入境管理法》第九条规定，中国公民出境入境，应当依法申请办理护照或者其他旅行证件。中国公民前往其他国家或者地区，还需要取得前往国签证或者其他入境许可证明，即我国公民出境时需持有效护照及签证。其次，旅行卡计划是亚太经合组织为促进本地区贸易投资便利化所作的一项多边签证安排。旅行卡有效期为5年，持卡人在有效期内凭旅行卡和与旅行卡相关联的有效护照，可多次出入相关经济体，并享受快速通关便利，即APEC商务旅行卡是多边签证集合体。最后，公诉机关证明内地居民持APEC旅行卡和因私护照出境时，需经边检站查验其旅行卡与护照无误后加盖验讫章方可放行。由此可见，APEC商务旅行卡与签证具有同样的功能，即入境许可证明，将APEC商务旅行卡认定为出入境证件，没有超出《中华人民共和国刑法》及司法解释关于“出入境证件”的语义范围，也没有超出一般人的认知范围，不属于扩大解释。

二、苏某某、朱某构成出售出入境证件罪

从全案证据来看，被告人苏某某以营利为目的，自行推广或通过朱某等人

招揽客户，约定高额报酬后，为不符合申请条件的人员伪造材料申办APEC卡，不属于提供咨询、协助、递送等服务的代办行为。苏某某、朱某为不符合申领条件的购卡人伪造资料申办APEC商务旅行卡的目的亦不是“为组织他人偷越国(边)境使用”，故其行为也不构成骗取出境证件罪。